

GUTACHTEN

erstattet der

DOCUMED AG, BASEL

von

PROF. DR. GERHARD SCHMID

Professor an der Universität Basel

und

DR. FELIX UHLMANN, LL.M.

Lehrbeauftragter an der Universität Basel

zur

ZULÄSSIGKEIT DER TÄTIGKEIT VON SWISSMEDIC
IM BEREICH DES SCHWEIZERISCHEN ARZNEIMITTELKOMPENDIUMS

* * *

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS	2
I. AUSGANGSLAGE	3
1. SACHVERHALT	3
2. GESETZLICHE GRUNDLAGEN IM ÜBERBLICK	4
II. GUTACHTENSAUFTRAG	5
III. WIRTSCHAFTSFREIHEIT	5
1. SCHUTZBEREICH	5
2. MONOPOLISIERUNG DURCH DAS GEMEINWESEN	7
a) <i>Begriff</i>	7
b) <i>Gesetzliche Grundlage</i>	8
aa) Verfassungsvorbehalt	8
bb) Gesetzesrecht (HMG)	8
cc) Verordnungsrecht (VAM, AMZV)	11
c) <i>Öffentliches Interesse und Verhältnismässigkeit</i>	13
aa) Verbot von Fiskalmonopolen	13
bb) Gesundheitsschutz	14
cc) Wettbewerbsinteressen	15
3. SCHUTZ VOR KONKURRENZIERUNG DURCH DAS GEMEINWESEN	16
a) <i>Staatliche Wirtschaftstätigkeit in Konkurrenz zur Privatwirtschaft</i>	16
aa) Unternehmerische Betätigung des Staates und privatwirtschaftliche Erwerbstätigkeit nach Art. 27 BV	16
bb) Veröffentlichung des Arzneimittelkompendiums als unternehmerische Betätigung	17
b) <i>Gesetzliche Grundlage</i>	19
c) <i>Öffentliches Interesse</i>	20
d) <i>Grundsatz der Wettbewerbsneutralität</i>	21
e) <i>Vergabe eines öffentlichen Auftrages</i>	22
IV. VERTRAUENSSCHUTZ	22
V. ZIVILRECHT	23
VI. BEANTWORTUNG DER GUTACHTENSFRAGEN	23

I. AUSGANGSLAGE

1. Sachverhalt

1. Seit dem Jahre 1979 ist Documed Herausgeberin und Verlegerin des Arzneimittel-Kompends der Schweiz. Documed führt im Kompendium rund 3'500 Fachinformationen und rund 3'000 Patienteninformationen in deutscher und französischer Sprache auf. Seit 1998 ist das Arzneimittel-Kompendum auf dem Internet online abrufbar. Das gedruckte Arzneimittelkompendium enthält die Arzneimittel-Fachinformation; die Patienteninformation wird von Documed nur noch elektronisch publiziert.

Documed gibt das gedruckte Arzneimittel-Kompendum an Fachpersonen (zur Verschreibung, Abgabe oder Anwendung von Humanarzneimitteln berechnigte Personen) unentgeltlich ab. Finanziert wird das Arzneimittel-Kompendum durch Zahlungen der Zulassungsinhaberinnen an Documed. Die erforderlichen Informationen werden Documed von den Zulassungsinhaberinnen aufgrund von Publikationsverträgen zur Verfügung gestellt. Die Arbeit von Documed besteht namentlich aus dem Erfassen, der redaktionellen Bearbeitung und der Kontrolle der Arzneimittelinformationen sowie der Strukturierung der Datensammlungen. Teilweise nimmt Documed auch Übersetzungen vor.

2. Im Swissmedic Journal 1/2004, S. 23 f. (mit gewissen Korrekturen im Swissmedic Journal 2/2004, S. 148) hat Swissmedic betreffend Arzneimittelinformation verschiedene Praxisänderungen angekündigt. Nebst Präzisierungen bezüglich die Form der Veröffentlichung teilt Swissmedic mit, dass sie

"im Hinblick auf die hervorragende Bedeutung eines einzigen umfassenden Nachschlagewerks für Arzneimittelinformationen [...] in Aussicht nimmt, die Fach- und Patienteninformation mittelfristig selber zu publizieren" (Swissmedic Journal 1/2004, S. 24).

Wie Documed unlängst erfahren hat, beruht diese Ankündigung auf einem entsprechenden Beschluss des Institutrats von Ende 2003.

Im Swissmedic Journal wird auch festgehalten, dass derzeit das einzige Nachschlagewerk, welches die Anforderungen von Swissmedic "erfüllt bzw. übertrifft", das Arzneimittel-Kompendum von Documed sei (Swissmedic Journal, a.a.O.). Dies hat Swissmedic gegenüber Documed auch in mehreren individuellen Schreiben bestätigt. Swissmedic hat auch unlängst einem Konkurrenten von Documed

mitgeteilt, dass dessen online Publikation von Patienteninformationen den gesetzlichen Anforderungen entspreche.

3. Am 8. Februar 2005 hat Swissmedic Gespräche mit Vertretern der Industrie geführt. Dabei hat Swissmedic die Absicht bekannt gegeben, für die zukünftige Herausgabe des Arzneimittelkompendiums eine Ausschreibung nach WTO-Kriterien durchzuführen. Was im Einzelnen Gegenstand der Ausschreibung sein soll, ist im heutigen Zeitpunkt nicht bekannt.

2. Gesetzliche Grundlagen im Überblick

4. Gemäss Art. 13 Abs. 2 Verordnung des Schweizerischen Heilmittelinstituts über die Anforderungen an die Zulassung von Arzneimitteln (Arzneimittelzulassungsverordnung, AMZV, SR 812.212.22) vom 9. November 2001 muss die ZulassungsinhaberIn die Arzneimittel-Fachinformation den Adressatinnen und Adressaten "auf geeignete Weise" zur Verfügung stellen. Ebenso muss die ZulassungsinhaberIn jeder von ihr vertriebenen Packung eines Humanarzneimittels eine Patienteninformation als Packungsbeilage beifügen und die Patienteninformation auch den zur Abgabe von Arzneimitteln berechtigten Personen zur Verfügung stellen (Art. 14 Abs. 1 AMZV). Arzneimittel-Fachinformation und Patienteninformation bilden zusammen die Arzneimittelinformation.
5. Die vorgenannten Veröffentlichungspflichten der Zulassungsinhaberinnen finden sich heute (auch) in Art. 16a Verordnung (des Bundesrates) über die Arzneimittel (Arzneimittelverordnung, VAM, SR 812.212.21) vom 17. Oktober 2001 (Änderung vom 18. August 2004). Gemäss dieser Bestimmung muss die ZulassungsinhaberIn die jeweils aktuelle, durch das Institut genehmigte Arzneimittelinformation den zur Abgabe dieser Arzneimittel berechtigten Personen "*auf geeignete Weise zur Verfügung stellen*" (Art. 16a Abs. 1 VAM). Die ZulassungsinhaberIn muss gegenüber Swissmedic die Erfüllung dieser Pflicht belegen (Art. 16a Abs. 2 VAM). In Art. 16a Abs. 3 VAM findet sich die Berechtigung von Swissmedic, die Arzneimittelinformation auf Kosten der ZulassungsinhaberIn "selber veröffentlichen oder veröffentlichen [...] lassen." Auf die Auslegung dieser Bestimmungen ist zurückzukommen.

II. GUTACHTENSAUFTRAG

6. Im Rahmen des Gutachtens sind aus rechtlicher Sicht folgende Fragen zu beantworten:
 1. Ist es zulässig, dass Swissmedic unter Ausschluss aller übrigen Anbieter die Arzneimittelinformationen veröffentlicht? Spielt es für die Zulässigkeit eine Rolle, ob diese Veröffentlichung durch Swissmedic selbst oder durch Dritte nach Durchführung einer Ausschreibung erfolgt?
 2. Ist es zulässig, dass Swissmedic in Konkurrenz zu allen übrigen Anbietern Arzneimittelinformationen veröffentlicht? Spielt es dabei eine Rolle, ob diese Veröffentlichung durch Swissmedic selbst oder durch Dritte nach Durchführung einer Ausschreibung erfolgt?

III. WIRTSCHAFTSFREIHEIT

1. Schutzbereich

7. Gemäss Art. 27 Abs. 1 BV ist die Wirtschaftsfreiheit gewährleistet. Bund und Kantone halten sich an den Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit (Art. 94 Abs. 1 BV). Auszugehen ist von einer freiheitlichen, wettbewerbsorientierten Wirtschaftsverfassung (RENÉ RHINOW, Grundzüge des Schweizerischen Verfassungsrechts, Basel 2003, N. 2854).
8. In den Schutzbereich der Wirtschaftsfreiheit fallen *privatwirtschaftliche Tätigkeiten* (vgl. nur Art. 27 Abs. 2 und Art. 95 BV). "[D]ie Ausübung einer staatlichen Tätigkeit oder eines öffentlichen Amtes [steht] nicht unter ihrem Schutz" (BGE 130 I 26 ff., 40). Kein Schutz besteht etwa für die ärztliche Tätigkeit im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Anstalt in einem entsprechenden Dienstverhältnis (BGer., a.a.O.) oder für die Tätigkeit von Urkundspersonen (BGE 128 I 280 ff., 281 f. E. 3). Ein Beamter kann sich Immerhin auf Wirtschaftsfreiheit berufen, wenn er beabsichtigt, in seiner Freizeit eine privatwirtschaftliche, mit seiner amtlichen Funktion in keinem Zusammenhang stehende Tätigkeit auszuüben (BGE 121 I 326 ff., 329). Vorab ist somit zu prüfen, ob die Veröffentlichung des Arzneimittelkompendiums überhaupt eine privatwirtschaftliche Tätigkeit darstellt, welche unter den Schutz der Wirtschaftsfreiheit fällt.

9. Die Veröffentlichung des Arzneimittelkompendiums erfolgt auf *Grundlage eines privatrechtlichen Vertrages* zwischen Documed und der jeweiligen Zulassungsinhaberin. Die Zulassungsinhaberin erfüllt mit der Veröffentlichung zwar eine gesetzliche Pflicht (Art. 16a Abs. 1 VAM). Unbestritten ist auch, dass die Publikation dem Gesundheitsschutz dient und damit im öffentlichen Interesse liegt. Dies spricht jedoch nicht gegen die privatwirtschaftliche Natur der Tätigkeit der Documed. Beispielsweise ist die Beratung von Steuerpflichtigen und das Vorbereiten einer Steuererklärung (selbstverständlich) eine privatwirtschaftliche Tätigkeit, auch wenn das Ausfüllen einer Steuererklärung gesetzliche Pflicht ist. Ebenso übt der Garagist, welcher für einen Privaten ein Fahrzeug bei der Motorfahrzeugkontrolle vorführt, eine privatwirtschaftliche Tätigkeit aus, auch wenn die Vorführung der Verkehrssicherheit dient und damit im öffentlichen Interesse liegt.
10. Die Tätigkeit der Documed erfolgt gegen *Entgelt*. Documed hat keine Kompetenz, von den Zulassungsinhaberinnen einseitig Gebühren zu erheben; die Zulassungsinhaberinnen sind auch nicht zur Publikation bei Documed verpflichtet, soweit eine andere Publikationsmöglichkeit besteht (Swissmedic Journal 1/2004, S. 23 f.). Neben der eigentlichen Publikation bietet Documed den Zulassungsinhaberinnen weitere Dienstleistungen (Übersetzungen etc.) an, welche ebenfalls Gegenstand privatrechtlicher Entschädigungen sind. Zweck der Documed (AG) ist eine gewinnorientierte Tätigkeit – was selbstverständlich eine hohe Qualität der Arbeit von Documed im Bereich des Arzneimittelkompendiums nicht ausschliesst, sondern voraussetzt.
11. Documed besitzt *keine staatlich verliehenen Privilegien* gegenüber anderen Marktteilnehmern. Ob solche unter dem Regime der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS) bestanden, kann vorliegend offen gelassen werden. Mit Schreiben vom 19. November 2002 hat Swissmedic allfällig noch bestehende Rechte und Pflichten per 31. Dezember 2003 gekündigt. In weiteren Schreiben vom 9. Oktober 2003 und 23. November 2004 wird Documed zwar bestätigt, dass sie die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Eine Bewilligungserteilung oder gar Konzessionierung einer amtlichen Tätigkeit liegt nach Auffassung von Swissmedic aber nicht vor. Damit stimmt überein, dass die staatliche Regelung zwar die Qualität der Arzneimittelinformation betrifft, nicht aber das Verhältnis zwischen Zulassungsinhaberin und Documed. Auch dies spricht für das Vorliegen einer privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit.

12. Schliesslich ist festzuhalten, dass die Trägerschaft von Documed rein privatrechtlich organisiert ist. Staatliche Einflussnahme oder gar Beherrschung liegt aufgrund der heutigen Eigentumsverhältnisse an den Aktien der Documed nicht vor.
13. Aus dem Gesagten ergibt sich, dass es sich bei der Veröffentlichung des Arzneimittelkompendiums in der heutigen Form um eine privatwirtschaftliche Tätigkeit i.S.v. Art. 27 und Art. 94 f. BV handelt. Das Angebot von Documed ist privatrechtlich organisiert und auf Erwerb ausgerichtet. Hinweise für staatliches Handeln (staatliche Vorrechte, Einflussnahme der öffentlichen Hand), welches vom Schutzbereich der Wirtschaftsfreiheit ausgeschlossen wäre, liegen nicht vor.

2. Monopolisierung durch das Gemeinwesen

a) Begriff

14. Ein staatliches Monopol liegt vor, "wenn der Staat das Recht hat, eine bestimmte wirtschaftliche Tätigkeit unter Ausschluss aller andern Personen auszuüben oder durch Dritte ausüben zu lassen" (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl., Zürich 2003, N. 2557). Eine Monopolisierung ist nicht nur dann anzunehmen, wenn eine bestimmte wirtschaftliche Tätigkeit Privaten durch Rechtsnormen untersagt wird (sog. direktes Monopol), sondern auch dann, wenn Privaten die Benutzung einer bestimmten öffentlichen Stelle zwingend vorgeschrieben ist (sog. indirektes Monopol). Im Falle eines indirekten Monopols ist die fragliche Tätigkeit zwar nicht verboten, es besteht aber kein Markt, weil der Zwang zur Benutzung einer staatlichen Einrichtung ein privates Angebot ausschliesst (HÄFELIN/MÜLLER, a.a.O., N. 2561 ff. m.w.H.).
15. Im vorliegenden Fall ist nicht damit zu rechnen, dass die Tätigkeit der Documed direkt verboten wird. Zieht aber Swissmedic in Betracht, die Fach- und Patienteninformation mittelfristig selber zu publizieren (Swissmedic Journal 1/2004, S. 24), so zeichnet sich diesbezüglich eine indirekte Monopolisierung ab: Zulassungsinhaberinnen würden etwa im Rahmen der Zulassungsverfügung verpflichtet, ihre Informationen durch Swissmedic publizieren zu lassen. Aufgrund einer solchen Monopolisierung würde jede weitere Betätigung von Documed in ihrem Kerngeschäft, der Veröffentlichung des Arzneimittelkompendiums, verunmöglicht.

Adien
Monopol:)

b) Gesetzliche Grundlage

aa) Verfassungsvorbehalt

16. Monopole des Bundes müssen sich auf eine Einzelermächtigung der Bundesverfassung stützen. Auch eine umfassende Gesetzgebungskompetenz des Bundes vermag eine zulässige Grundlage zu bilden (HÄFELIN/MÜLLER, a.a.O., N. 2571).
17. Die Gesetzgebungstätigkeit des Bundes beruht vorliegend auf Art. 118 Abs. 2 lit. a BV, wonach der Bund Vorschriften über den Umgang mit Heilmitteln erlässt. Der Bundesverfassung sind keine weiteren Angaben zu entnehmen, ob damit auch eine exklusive Publikation der Arzneimittelinformationen durch Swissmedic abgedeckt ist (vgl. etwa LUZIUS MADER, Art. 118, in: Bernhard Ehrenzeller et al. [Hrsg.], Die schweizerische Bundesverfassung, Zürich 2002, S. 1206 ff.). Mit Blick auf die Tatsache, dass es sich bei der fraglichen Tätigkeit um einen vergleichsweise geringen Ausschnitt des Heilmittelrechts handelt und unter Berücksichtigung des weiten Ermessens des Gesetzgebers bei der Umsetzung von Verfassungsrecht ist einer möglichen Monopolisierung der Arzneimittelinformation nicht von vorneherein die notwendige Verfassungsgrundlage abzusprechen. Eine Monopolisierung durch den Gesetzgeber ist somit nicht ausgeschlossen.
18. Immerhin ist auch der Gesetzgeber aufgerufen, der Zielsetzung im Heilmittelbereich Rechnung zu tragen. Vorrangiges Ziel der Heilmittelgesetzgebung ist der "Schutz der Gesundheit" (Art. 118 Abs. 1 BV). Es darf angenommen werden, dass diese Zielsetzung auch den Kompetenzrahmen des Bundes beeinflusst: Dort wo die Gesetzgebung des Bundes ein ausgewiesenes gesundheitspolizeiliches Interesse verfolgt, ist die Zuständigkeit des Bundes gestützt auf Art. 118 Abs. 2 lit. a BV eher zu bejahen als in Bereichen, wo das entsprechende Interesse nur schwach ausgeprägt erscheint. Verfassungsrechtliche Kompetenz und öffentliches Interesse stehen insofern in einer Wechselwirkung. Auch der Gesetzgeber hat sich somit bei der Ausschöpfung seines Kompetenzrahmens zu fragen, inwiefern die Gesetzgebung legitimen gesundheitspolizeilichen Interessen dient.

bb) Gesetzesrecht (HMG)

19. Auf Gesetzesstufe ist für ein Monopol eine Grundlage in einem formellen Gesetz zu fordern, da die Monopolisierung einen schwerwiegenden Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit darstellt (RENÉ RHINOW/GERHARD SCHMID/GIOVANNI BIAGGINI, Öffentli-

ches Wirtschaftsrecht, Basel 1998, S. 366). Zu prüfen sind damit in erster Linie die Bestimmungen des Bundesgesetzes über Arzneimittel und Medizinprodukte (Heilmittelgesetz, HMG) vom 15. Dezember 2000 (SR 812.21).

20. Gemäss Art. 1 Abs. 2 lit. c HMG soll das Gesetz dazu beitragen, "dass eine sichere und geordnete Versorgung mit Heilmitteln, einschliesslich der dafür nötigen fachlichen Information und Beratung, im ganzen Land angeboten wird." Im Zulassungsgesuch muss die Gesuchstellerin unter anderem einen geeigneten Vorschlag betreffend Arzneimittelinformation unterbreiten (Art. 11 Abs. 1 lit. f HMG). Dass die Arzneimittelinformation, welche sich bereits *per definitionem* an das Publikum und an abgabeberechtigte Personen richtet, diesen auch zugänglich sein muss, versteht sich von selbst und ist ohne weiteres durch den Gesetzestext gedeckt.
21. Schwieriger zu beantworten ist die Frage, ob dem Gesetz Hinweise zu entnehmen sind, auf welche Weise die Verbreitung der Arzneimittelinformation zu erfolgen hat. Für eine mögliche Publikation durch Swissmedic ist vor allem Art. 67 HMG von Bedeutung. Diese Bestimmung lautet im vollen Wortlaut wie folgt:

"Information der Öffentlichkeit

¹ Das Institut sorgt dafür, dass die Öffentlichkeit über besondere Ereignisse im Zusammenhang mit Heilmitteln, welche die Gesundheit gefährden, informiert wird und Verhaltensempfehlungen erhält. Es veröffentlicht Informationen von allgemeinem Interesse aus dem Bereich Heilmittel, insbesondere über Zulassungs- und Widerrufsentscheide sowie Änderungen von Fach- und Patienteninformationen über Arzneimittel.

² Die zuständigen Bundesstellen können die Öffentlichkeit zum Schutz der Gesundheit und zur Bekämpfung des Heilmittelmissbrauchs über die sachgerechte Verwendung von Heilmitteln informieren."

Direkt angesprochen wird die Arzneimittelinformation in Art. 67 Abs. 1 Satz 2 HMG, wonach Swissmedic "insbesondere über ... Änderungen von Fach- und Patienteninformationen" orientiert. Der Passus ("... insbesondere ...") wurde erst im Rahmen der parlamentarischen Beratungen ins Gesetz aufgenommen; die entsprechenden Ratsprotokolle vom 13. März 2000 (Nationalrat) und vom 27. September 2000 (Ständerat) enthalten keine weiter führenden Erklärungen.

22. Dem Wortlaut der Bestimmung kann nicht entnommen werden, dass der Gesetzgeber beim Erlass von Art. 67 HMG nicht eine umfassende Veröffentlichung der Arzneimittelinformation durch Swissmedic beabsichtigte. Wäre diese von Art. 67 HMG erfasst, stünde die Frage im Raum, weshalb (mutmasslich unerwartete)

Änderungen der Arzneimittelinformation als Beispiel einer Information von allgemeinem Interesse genannt werden. Wenn Swissmedic ohnehin die gesamte Arzneimittelinformation veröffentlicht, so besteht keine Veranlassung, die Änderung von Arzneimittelinformationen im Gesetzestext als Beispiel zu nennen. Somit kann Art. 67 HMG nicht als Grundlage für eine umfassende Veröffentlichung der Arzneimittelinformation durch Swissmedic herangezogen werden.

23. Auch die Botschaft des Bundesrates, welche sich auf den Gesetzestext ohne Zusatz ("... insbesondere ...") bezieht, geht von einer *punktuellen Informationstätigkeit* von Swissmedic im Bereich der Arzneimittelinformation aus und stützt somit die hier vertretene Einschätzung. Im Zusammenhang mit Art. 66 Abs. 1 E-HMG spricht der Bundesrat von einer Information der Öffentlichkeit über aktuelle und konkrete Vorfälle. Gedacht wird auch an periodische Mitteilungen von allgemeinem Interesse, wie sie etwa heute durch das Swissmedic Journal geschieht (Botschaft zu einem Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte vom 1. März 1999, BBl 1999, 3453 ff., 3550).
24. Noch weniger erscheint Art. 67 Abs. 2 HMG als rechtliche Grundlage für eine Veröffentlichung der Arzneimittelinformation durch Swissmedic geeignet. In systematischer Hinsicht ist fraglich, ob Swissmedic durch Art. 67 Abs. 2 HMG überhaupt erfasst wird ("... zuständige Bundesstellen ..."), ist doch ihre Informationstätigkeit Gegenstand der Regelung nach Art. 67 Abs. 1 HMG. Auch die Informationstätigkeit nach Art. 67 Abs. 2 HMG hat überdies *punktuellen Charakter*; gemäss Botschaft zu Art. 66 Abs. 2 E-HMG (= Art. 67 Abs. 2 HMG) ist etwa an "öffentliche Kampagnen" zu denken.
25. Insgesamt ergibt sich, dass der Gesetzgeber in Art. 67 HMG eine Veröffentlichung der gesamten Arzneimittelinformation durch Swissmedic nicht beabsichtigte. Auch wenn man in Rechnung stellt, dass gemäss – diskutabler – Ansicht die Anforderungen an die gesetzliche Grundlage im Bereich staatlicher Information möglicherweise herabgesetzt sind (vgl. CAROLINE BARTHE, Zur Informationstätigkeit der Verwaltung unter besonderer Berücksichtigung des Umweltschutzgesetzes des Bundes, Diss., Basel 1993, S. 125 ff., 131 ff.; PATRICK NÜTZI, Rechtsfragen verhaltenslenkender Information, Diss., Bern 1995, S. 105 ff.; PAUL RICHLI, Öffentlich-rechtliche Probleme bei der Erfüllung von Staatsaufgaben mit Informationsmitteln, ZSR 109 [1990], I. Halbband, S. 260 ff.), kann vorliegend *Art. 67 HMG nicht als genügende gesetzliche Grundlage zur Monopolisierung des Arzneimittelkompendiums durch Swissmedic herangezogen werden*. Sowohl in

demokratischer Hinsicht wie auch mit Blick auf die Vorhersehbarkeit der gesetzlichen Regelung, dass mit der vorliegenden gesetzlichen Regelung den Anforderungen an die gesetzliche Grundlage im Sinne von Art. 36 Abs. 1 Satz 2 BV nicht hinreichend Genüge getan wird (vgl. allgemein RHINOW, a.a.O., N. 1110 ff.).

cc) Verordnungsrecht (VAM, AMZV)

26. Der Vollständigkeit halber sind vorliegend auch die Grundlagen im Verordnungsrecht zu prüfen. Dies erscheint nicht nur als Variante für den Fall angezeigt, wonach Art. 67 HMG als eine ausreichende formell-gesetzliche Grundlage für die Veröffentlichung des Arzneimittelkompendiums erachtet wird. Vielmehr kann ein Blick auf die Grundlagen im Verordnungsrecht auch Rückschlüsse erlauben, wie die Bestimmungen auf Gesetzesstufe zu verstehen sind.
27. Im Zentrum der nachfolgenden Überlegungen steht Art. 16a VAM. Diese Bestimmung hat folgenden Wortlaut:

"Veröffentlichung

¹ *Die Inhaberin einer Zulassung für Humanarzneimittel ist verpflichtet, die jeweils aktuelle, durch das Institut genehmigte Arzneimittelinformation den zur Verschreibung, Abgabe oder Anwendung dieser Arzneimittel berechtigten Personen auf geeignete Weise zur Verfügung zu stellen.*

² *Sie muss dem Institut belegen, dass sie diese Pflicht erfüllt hat.*

³ *Das Institut kann die Arzneimittelinformation auf Kosten der Zulassungsinhaberin selber veröffentlichen oder veröffentlichen lassen."*

28. Die entsprechende Verordnungsbestimmung ist zusammen mit anderen Bestimmungen des Heilmittelverordnungspakets II vom 18. August 2004 erlassen worden und gilt seit 1. September 2004. Soweit ersichtlich findet sich Art. 16a VAM jedoch weder in den Erläuterungen des Bundesamtes für Gesundheit vom 5. Juni 2003 zum Heilmittelverordnungspaket II noch anderen öffentlich zugänglichen Erläuterungen und ist erst kurz vor Verabschiebung durch den Bundesrat aufgenommen worden. Interessierte Kreise konnten sich somit zu dieser Bestimmung nicht äussern; Erläuterungen der Behörden fehlen. Der Hintergrund der Einführung dieser Bestimmung bleibt in diesem Sinne unklar.
29. Rechtlich unterhalb der Stufe der VAM (Verordnung des Bundesrates) regelt eine Verordnung von Swissmedic vom 9. November 2001 über die Anforderungen an

die Zulassung von Arzneimitteln (Arzneimittel-Zulassungsverordnung, AMZV, SR 812.212.22) die Einzelheiten der Arzneimittelinformation (Art. 13 f.; Anhänge 4 und 5). Betreffend Veröffentlichung findet sich in Art. 13 Abs. 2 AMZV die Bestimmung, wonach die Zulassungsinhaberin den Adressatinnen und Adressaten die Information "in geeigneter Weise" zur Verfügung stellen muss. In den Anhängen 4, 5.1, 5.2 und 5.3 findet sich jeweils der Passus, dass die Zulassungsinhaberin die Veröffentlichung der Arzneimittelinformation nachweisen muss, *sofern Swissmedic die entsprechende Information nicht selbst publiziert*. Diese Bestimmungen bilden allerdings nach der hier vertretenen Auffassung nicht selbst die Grundlage zur Publikation des Arzneimittelkompendiums durch Swissmedic, sondern regeln die Pflichten der Zulassungsinhaberin *für den Fall*, dass Swissmedic die Publikation – gestützt auf andere gesetzliche Bestimmungen – selbst übernehmen sollte. Im Übrigen bedarf selbstverständlich eine Verordnung von Swissmedic einer Delegationsnorm im Gesetzes- oder übergeordneten Verordnungsrecht. Letzteres ist Gegenstand der folgenden Überlegungen.

30. Art. 16a Abs. 1 VAM verpflichtet zunächst die Zulassungsinhaberin, die Arzneimittelinformation den Anwenderinnen und Anwendern "in geeigneter Form" zur Verfügung zu stellen. Die grundsätzliche Verpflichtung der Zulassungsinhaberin zur Information findet somit heute auf Verordnungsstufe eine eindeutige gesetzliche Grundlage. Soweit erscheint Art. 16a VAM klar.
31. Schwieriger zu erfassen ist die Bedeutung von Art. 16a Abs. 2 und 3 VAM. Art. 16a Abs. 2 VAM verpflichtet die Zulassungsinhaberin, die Erfüllung ihrer Informationspflicht gegenüber Swissmedic zu belegen. Art. 16a Abs. 3 VAM gibt Swissmedic Möglichkeit, die Arzneimittelinformation auf Kosten der Zulassungsinhaberin selbst zu veröffentlichen oder veröffentlichen zu lassen.

Im Kontext mit Art. 16a Abs. 2 VAM ist nach der hier vertretenen Auffassung von einer engen Interpretation auszugehen: Danach räumt Art. 16a Abs. 3 VAM Swissmedic lediglich die Kompetenz ein, die Arzneimittelinformation *ausserhalb* zu publizieren, sofern eine Zulassungsinhaberin ihrer Verpflichtung zur Publikation nicht nachkommt (Ersatzvornahme). Die Zuständigkeit von Swissmedic erscheint somit subsidiär und setzt ein Versäumnis der Zulassungsinhaberin voraus.

32. Für diese Interpretation spricht auch, dass Art. 16a Abs. 3 VAM die Zulassungsinhaberin im Singular nennt; das Gleiche gilt für den französischen Gesetzestext

("L'institut peut publier ou faire publier l'information sur le médicament, aux frais du titulaire de l'autorisation."). Es ist somit *die* Zulassungsinhaberin, welche die Erfüllung ihrer Informationspflicht nachweisen muss (Art. 16a Abs. 2 VAM), und es ist *die* (säumige) Zulassungsinhaberin, welche für die Kosten der Publikation in Anspruch genommen wird.

33. Dem kann entgegen gehalten werden, dass bei dieser Interpretation die Bedeutung von Art. 16a Abs. 3 VAM sehr beschränkt ist. Art. 16a Abs. 3 VAM sagt somit nicht anderes, als was sich schon aus allgemeinen Grundsätzen des Verwaltungsrechts herleiten liesse, nämlich die Ersatzvornahme durch das Gemeinwesen. Ein selbstständiger Sinn von Art. 16a Abs. 3 VAM ist somit kaum erkennbar.

Allerdings liesse sich die gleiche Bemerkung auch für Art. 16a Abs. 2 VAM anbringen. Die Verpflichtung eines Privaten, die Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht zu belegen, ist vorliegend ein ebenso selbstverständlicher Bestandteil des verwaltungsrechtlichen Vollzugs wie die Möglichkeit des Gemeinwesens zur Ersatzvornahme (Art. 16a Abs. 3 VAM).

Damit soll nicht gesagt werden, dass Art. 16a Abs. 2 und 3 VAM überflüssig sind; immerhin dienen sie möglicherweise der Klarstellung und der Orientierung der Rechtsunterworfenen. Es geht vorliegend lediglich um die Feststellung, dass eine Interpretation von Art. 16a Abs. 3 VAM nicht aussergewöhnlich erscheint, die der entsprechenden Bestimmung keine oder nur eine geringe selbstständige Bedeutung beimisst. Auch auf Verfassungsebene findet sich eine Vielzahl von Bestimmungen mit deklaratorischem Charakter.

34. *Insgesamt ist deshalb aufgrund der vorliegenden Unterlagen auch auf Verordnungsstufe anzunehmen, dass Swissmedic für die Monopolisierung des Arzneimittelkompendiums über keine hinreichende gesetzliche Grundlage verfügt.*

c) Öffentliches Interesse und Verhältnismässigkeit

aa) Verbot von Fiskalmonopolen

35. Zu prüfen ist weiter, ob die Monopolisierung des Arzneimittelkompendiums im öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig ist (Art. 36 Abs. 2 und 3 BV).
36. Unbestritten ist zunächst, dass eine Monopolisierung unzulässig ist, wenn sie in erster Linie aus fiskalischen Erwägungen geschieht (RHINOW/SCHMID/BIAGGINI,

a.a.O., S. 367 f.). Akzeptiert wird vom Bundesgericht lediglich, dass ein polizeilich oder sozialpolitisch gerechtfertigtes Monopol einen gewissen Reingewinn abwirft (BGE 124 I 11 ff., 17 ff.; kritisch dazu HÄFELIN/MÜLLER, a.a.O., N. 2581).

37. Überdies werden fiskalische Überlegungen des Gemeinwesens weniger streng beurteilt, sofern das Gemeinwesen eine bestimmte ohnehin ausgeübte Tätigkeit nebenbei kommerzialisiert (sog. "Randnutzung von Verwaltungsvermögen", vgl. etwa GERHARD SCHMID/FELIX UHLMANN, Öffentliche Unternehmen in den Untiefen zwischen Grundrechtsbindung, Gewinnorientierung und Sachen im Gemeingebrauch – Gutachten über die Zulässigkeit der Exklusivvergabe der Baselland Transport AG [BLT] für das Aufstellen von Zeitungsboxen an Tramhaltestellen im Kanton Basel-Landschaft, ZBl 102 [2001], S. 337 ff., 341 f.). Die faktischen und rechtlichen Voraussetzungen der Randnutzung von Verwaltungsvermögen wären beispielsweise näher zu prüfen, wenn Swissmedic bereits heute Herausgeberin des Arzneimittelkompendiums wäre und dieses Kompendium respektive die darin enthaltenen Daten für weitere nicht gesetzlich vorgeschriebene Verwendungen Dritten entgeltlich überlassen würde. Dies entspricht aber nicht den heute vorgefundenen Verhältnissen. Es bleibt somit bei der Prämisse, dass die Herausgabe des Arzneimittelkompendiums durch andere als fiskalische Gründe gerechtfertigt sein muss.

bb) Gesundheitsschutz

38. Zur Rechtfertigung der Monopolisierung des Arzneimittelkompendiums ist mit Blick auf die Zielsetzung in Art. 118 Abs. 1 BV und Art. 1 HMG in erster Linie an Interessen des Gesundheitsschutzes zu denken. Es steht ausser Frage, dass gesundheitspolizeiliche Interessen eine taugliche Rechtfertigung für die Monopolisierung der Arzneimittelinformation darstellen könnten.
39. Solche sind aber derzeit nicht ersichtlich. Auch Swissmedic hält fest, dass derzeit ein Arzneimittelkompendium besteht, welches die gesetzlichen Anforderungen "erfüllt bzw. übertrifft" (Swissmedic Journal 1/2004, S. 24). An dieser Sachlage dürfte sich nichts geändert haben, auch wenn Swissmedic in der Zwischenzeit einen Konkurrenten zur online Veröffentlichung der Patienteninformation "zuge lassen" hat. *Es ist deshalb nicht ersichtlich, welche gesundheitspolizeilichen Interessen vorliegend eine Monopolisierung rechtfertigen sollen.*

40. Zu überlegen ist allerdings, ob sich an diesem Zustand in Zukunft etwas ändern könnte. Denkbar ist ein Auftreten einer Vielzahl von privaten Anbietern im Bereich der Arzneimittelinformation mit entsprechender Zersplitterung des Marktes.⁸ In diese Richtung lässt sich zumindest folgende Aussage von Swissmedic verstehen (Swissmedic Journal 1/2004, S. 24, Hervorhebung nur hier):

"Im Hinblick auf die hervorragende Bedeutung eines einzigen, umfassenden Nachschlagewerks für Arzneimittelinformationen für die Arzneimittelsicherheit nimmt Swissmedic in Aussicht, die Fach- und Patienteninformationen mittelfristig selber zu publizieren."

Ohne zu einer solchen Entwicklung abschliessend Stellung zu nehmen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine solche Zersplitterung zu Qualitätseinbussen führen könnte, welche eine aktivere Rolle von Swissmedic gerechtfertigt erscheinen lassen würde. Allerdings darf natürlich nicht ein Markteintritt von Swissmedic selbst dazu führen, dass in der Folge eine Monopolisierung wegen Zersplitterung geboten erscheint.

Die Frage wird vorliegend offen gelassen, da selbst bei Zutreffen der entsprechenden Befürchtungen eine Monopolisierung im heutigen Zeitpunkt rechtlich unzulässig erscheint. Angesprochen ist der Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit. Unter diesem Prinzip erscheint nicht nur bedenklich, dass mit einer umfassenden Monopolisierung einzig der *schwerstmögliche Eingriff* in Betracht gezogen wird. Problematisch erscheint auch, dass ein solcher Eingriff *präventiv* erfolgt. Auch unter Berücksichtigung des im Heilmittelrecht geltenden Vorsorgeprinzips (vgl. dazu etwa FELIX UHLMANN, Der Risikobegriff im schweizerischen und europäischen Heilmittelrecht, in: Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 2004, S. 517 ff., 525 ff.) ist die Monopolisierung mindestens unter dem Gesichtspunkt der *Verhältnismässigkeit* als unzulässig anzusehen.

cc) Wettbewerbsinteressen

41. Zu überlegen ist schliesslich, ob eine Intervention von Swissmedic gerechtfertigt ist, um die starke Marktstellung von Documed mittels einer transparenten Vergabe an private Dritte aufzuheben. Zweck der Monopolisierung wäre vereinfacht gesagt die Ablösung einer privaten Marktführerin durch die öffentliche Hand oder einen konzessionierten Dritten. Wettbewerb im Markt würde durch Wettbewerb um den Markt ersetzt. Ohne vorliegend zur Frage der Marktbeherrschung i.S.v. Art. 4 Abs. 2 KG durch Documed vertieft Stellung zu nehmen, erscheint eine solche Rechtfertigung nicht tragfähig.

42. Fraglich ist zunächst, ob Swissmedic im Rahmen ihres Auftrages nach Art. 1 HMG überhaupt aufgerufen ist, eine eigentliche Wettbewerbspolitik zu betreiben. Richtig ist zwar, dass gemäss Art. 1 Abs. 3 HMG "die miteinander im Wettbewerb stehenden Marktpartner den gleichen gesetzlichen Sicherheits- und Qualitätsanforderungen genügen" sollen. Damit ist der Grundsatz der Wettbewerbsneutralität angesprochen. Dass aber Swissmedic gestützt auf diese Grundlage eine Monopolisierung des Arzneimittelkompendiums und eine nachfolgende Ausschreibung zwecks Veranstaltung von Wettbewerb unter Anbletern durchführen kann, ist abzulehnen.
43. Auch aus Sicht des Wettbewerbsrechts erscheint es unzulässig, die Tätigkeit eines marktführenden Unternehmens zu verstaatlichen, um sie anschliessend zum Gegenstand des Wettbewerbs mittels Vergabe zu machen. Zu erwähnen ist nur Art. 7 KG, wonach nicht die Marktbeherrschung per se, sondern nur bestimmte Verhaltensweisen marktbeherrschender Unternehmen verboten sind.
44. Eine Monopolisierung erscheint deshalb auch aus Gründen des Wettbewerbs kaum gerechtfertigt. Damit ist zugleich die Frage beantwortet, ob die Veranstaltung von (beschränktem) Wettbewerb mittels Ausschreibung eine Monopolisierung zu rechtfertigen vermag. *Nach der hier vertretenen Auffassung trägt eine Ausschreibung nichts zur Rechtfertigung einer vorgängigen Monopolisierung bei. Eine Monopolisierung ist deshalb sowohl mangels gesetzlicher Grundlage wie auch wegen fehlendem öffentlichen Interesse abzulehnen.*

3. Schutz vor Konkurrenzierung durch das Gemeinwesen

a) Staatliche Wirtschaftstätigkeit in Konkurrenz zur Privatwirtschaft

aa) Unternehmerische Betätigung des Staates und privatwirtschaftliche Erwerbstätigkeit nach Art. 27 BV

45. Swissmedic "nimmt in Aussicht" (Swissmedic Journal 1/2004, S. 24), die Fach- und Patienteninformation mittelfristig selber zu publizieren. Vorstehend (Ziff. 2) wurde davon ausgegangen, dass Swissmedic die Herausgabe des Arzneimittelkompendiums monopolisiert. Denkbar ist aber auch, dass Swissmedic ihre Dienstleistungen zunächst neben das bestehende privatrechtliche Angebot stellt und damit die Tätigkeit von Documed konkurrenziert.

46. Um die Auswirkungen staatlicher Konkurrenz durch Swissmedic auf die Wirtschaftsfreiheit rechtlich beurteilen zu können, ist zunächst einmal zu klären, ob es sich bei einem Angebot von Swissmedic zur Publikation in einem eigenen Arzneimittelkompendium um eine *unternehmerische Betätigung des Staates* handelt (vgl. dazu RHINOW/SCHMID/BIAGGINI, S. 357 ff.) oder um die *Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe*. Dabei ist zu beachten, dass diese Zuordnung nicht mit der Frage gleichgesetzt werden kann, ob es sich bei der fraglichen Tätigkeit um eine privatwirtschaftliche Erwerbstätigkeit i.S.v. Art. 27 u. Art. 94 f. BV handelt – was vorliegend bejaht wurde (vgl. oben Ziff. 8 ff.). So kann sich beispielsweise der Betreiber einer Privatschule auf die Wirtschaftsfreiheit berufen, wenn mit er entsprechenden staatlichen Verboten konfrontiert ist. Dies bedeutet aber nicht, dass der Staat selbst im Bereich des Schulwesens unternehmerisch tätig ist: "Der Staat kann sich ... aus bestimmten Gründen gerade zum Ziel setzen, gewisse Aufgaben zu erfüllen, ohne dafür einen marktgerechten Preis zu verlangen, insbesondere im Bestreben, diese Leistungen für alle Bevölkerungsschichten erschwinglich zu gestalten. Ob und wie weit dies der Fall sein soll, ist eine durch den demokratisch legitimierte Gesetzgeber zu beantwortende Frage" (BGE 123 I 254 ff., 256). Grundrechtlich geschützte Erwerbstätigkeit Privater und unternehmerische Tätigkeit des Staates sind also nicht deckungsgleich.

bb) Veröffentlichung des Arzneimittelkompendiums als unternehmerische Betätigung

47. Eine einheitliche Definition unternehmerischer Betätigung des Staates besteht nicht. Gemeinhin wird angenommen, dass der Staat unternehmerisch tätig wird, "wenn er wirtschaftliche Leistungen anbietet, welche von Dritten erworben werden können" (RENÉ RHINOW/GERHARD SCHMID/GIOVANNI BIAGGINI, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Basel 1998, S. 361 f.). Nicht begriffswesentlich sind der verfolgte Zweck, die Rechtsform sowie die rechtliche Qualifikation der Beziehungen zu den Abnehmern und Leistungsempfängern. Als entscheidender Gesichtspunkt erscheint die Produktion wirtschaftlicher Leistungen, verbunden mit dem Einsatz privatwirtschaftlicher Arbeitsmethoden (BEAT KRÄHENMANN, Privatwirtschaftliche Tätigkeit des Gemeinwesens, Diss., Basel 1987, S. 1 f.). Es darf angenommen werden, dass ein Tätigwerden von Swissmedic im Bereich des Arzneimittelkompendiums dieser Umschreibung entspricht.
48. Für das Vorliegen unternehmerischer Betätigung seitens von Swissmedic spricht vorliegend, dass der Bereich des Arzneimittelkompendiums Gegenstand einer

Untersuchung durch die WEKO ist. Dies deutet darauf hin, dass der untersuchte Bereich nach Ansicht der WEKO nicht in den Ausnahmereich von Art. 3 Abs. 1 KG fällt. Dieser Zusammenhang ist vom Bundesgericht unlängst bestätigt worden. In einem Entscheid vom 23. September 2004 (Urteil 2P.67/2004), E. 1.5 m.w.H., hielt das Gericht Folgendes fest:

"Der Grundsatz der Gleichbehandlung von öffentlichen und privaten Betrieben gilt aber dort nicht, wo der Staat im öffentlichen Interesse eine öffentliche Aufgabe wahrnimmt. Dies entspricht auch den wettbewerbsrechtlichen Regeln: Das Kartellrecht ist nicht anwendbar auf staatliche Unternehmen, die zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben mit besonderen Rechten ausgestattet sind ... Es unterscheidet damit zwischen einem öffentlichen, hoheitlichen Bereich, in welchem das Wettbewerbsrecht nicht gilt, und einem unternehmerischen Staatshandeln, welches den Wettbewerbsregeln untersteht ..."

Damit besteht im Bereich der unternehmerischen Betätigung des Gemeinwesens ein enger Zusammenhang zwischen wirtschaftsverfassungsrechtlicher und wettbewerbsrechtlicher Betrachtungsweise. Untersuchungen der WEKO sprechen tendenziell gegen einen öffentlichen, hoheitlichen Bereich, in welchem keine unternehmerische Betätigung des Staates stattfindet.

49. Gegen das Vorliegen unternehmerischer Betätigung von Swissmedic kann angeführt werden, dass die Veröffentlichung des Arzneimittelkompendiums zweifellos ein gewichtiges öffentliches Interesse erfüllt. Es wäre denkbar gewesen, dass der Gesetzgeber *ab initio* diese Aufgabe den Behörden zugewiesen hätte, ohne dass private Anbieter *später* diese Regelung unter Art. 27 respektive Art. 94 f. BV hätten in Frage stellen können. Im vorgenannten Entscheid vom 23. September 2004 (Urteil 2P.67/2004), E. 1.5 m.w.H., äussert das Bundesgericht klar die Auffassung, dass "die Wirtschaftsfreiheit auch in ihrer Ausprägung als Gleichbehandlung der Gewerbetreibenden bzw. Wettbewerbsneutralität keinen individualrechtlichen Schutz vor staatlicher Konkurrenz und keinen Rechtsanspruch darauf [gibt], dass der Staat eine bestimmte öffentliche Aufgabe nicht wahrnimmt oder unterstützt ...". Soweit aber eine bestimmte Tätigkeit, welche bisher von Privaten ausgeübt wurde, erst zur öffentlichen Aufgabe gemacht werden soll, ist Art. 27 BV betroffen. Die Wirtschaftsfreiheit bietet in diesem Sinne Schutz vor Verstaatlichung (RHINOW/SCHMID/BIAGGINI, S. 100 m.w.H.).
50. Gegen das Vorliegen einer staatlichen Aufgabe spricht schliesslich, dass die Pflicht zur Veröffentlichung der Arzneimittelinformation zunächst einmal den privaten Zulassungsinhaberinnen auferlegt wird (Art. 16a Abs. 1 VAM). Bietet

Swissmedic nun den Zulassungsinhaberinnen an, diese Aufgabe zu übernehmen, so führt sie eine Aufgabe in die staatliche Verantwortung zurück, welche gemäss gesetzlicher Konzeption zunächst eine private Pflicht darstellt. Swissmedic erfüllt mit anderen Worten nicht eine öffentliche Aufgabe, welche originär staatlichen Organen auferlegt wird, sondern übernimmt von Privaten gegen Entgelt die Erfüllung einer Pflicht, welche laut Gesetz den Privaten zugewiesen ist.

51. *Insgesamt ist deshalb davon auszugehen, dass Swissmedic unternehmerisch tätig wird, wenn sie in Konkurrenz zu Documed die Veröffentlichung der Arzneimittelinformation anbietet. Die Konsequenzen dieser Zuordnung sind nachfolgend zu untersuchen.*

b) Gesetzliche Grundlage

52. Für eine unternehmerische Tätigkeit des Gemeinwesens wird gefordert, dass sie auf einer *hinreichend klaren formell-gesetzlichen Grundlage* beruhen muss (vgl. RHINOW/SCHMID/BIAGGINI, a.a.O., S. 372). Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht erfüllt. Diesbezüglich kann auf die Ausführungen zur Monopolisierung verwiesen werden (vgl. oben Ziff. 19 ff.).
53. Zu beachten ist allerdings, dass Swissmedic als Verwaltungsträger dem sog. 3. Kreis zuzuordnen ist (Bericht der Geschäftsprüfungskommission des Ständerates vom 25. August 2004 über die Probleme von Swissmedic anlässlich der Inbetriebnahme und Beurteilung der heutigen Lage, BBl 2005, 273 ff., 284, 289, 318 ff.). Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben verfügt Swissmedic zweifellos über gewisse Autonomie. In unternehmerischer Hinsicht findet diese Autonomie Niederschlag in Art. 69 Abs. 2 HMG, wonach Swissmedic Behörden und Privaten gegen Entgelt Dienstleistungen erbringen kann. Die Botschaft nennt als Beispiel etwa die Durchführung von Seminarien (Botschaft, S. 3552). Zu denken ist auch an einzelne kostenpflichtige Abklärungen für Private.

Die umfassende Veröffentlichung des Arzneimittelkompendiums –

sprengt offensichtlich den Rahmen von Art. 69 Abs. 2 HMG. Zulässig wäre lediglich ein beschränktes Angebot, zu welchem Swissmedic aufgrund vorhandener Synergien besonders gut in der Lage wäre. Damit ist wiederum die Randnutzung von Verwaltungsvermögen angesprochen (vgl. oben Ziff. 37), von welcher aber

nicht gesprochen werden kann, wenn Swissmedic die umfassende Veröffentlichung des Arzneimittelkompendiums an sich zieht.

Der Vollständigkeit halber ist aber darauf hinzuweisen, dass auch bei einer Abstützung der unternehmerischen Tätigkeit von Swissmedic auf Art. 69 Abs. 2 HMG diese voll kostendeckend zu erbringen wäre. Sie dürfte nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung zu Lasten privater Anbieter führen (Botschaft zu einem Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte vom 1. März 1999, BBl 1999, 3453 ff., 3552).

c) Öffentliches Interesse

54. Unstreitig ist, dass jede unternehmerische Tätigkeit des Gemeinwesens auf einem hinreichenden öffentlichen Interesse beruhen muss. Ein rein fiskalisches Interesse des Gemeinwesens soll nicht ausreichen, um dessen unternehmerische Tätigkeit zu legitimieren (FELIX UHLMANN, Gewinnorientiertes Staatshandeln, Diss., Basel 1997, S. 29 ff.).

Weniger klar ist diese Vorgabe für die Randnutzung von Verwaltungsvermögen (UHLMANN, a.a.O., S. 100 ff.; vgl. auch Botschaft zum Bundesgesetz über die Stiftung Schweizerisches Landesmuseum vom 29. November 2002, BBl 2003, 535 ff., 574 ff.). Von einer solchen kann aber nicht gesprochen werden, wenn Swissmedic auf breiter Basis die Veröffentlichung der Arzneimittelinformation anbietet.

55. Hinsichtlich öffentlicher Interessen für die unternehmerische Betätigung von Swissmedic kann weitgehend auf die Überlegungen zur Monopolisierung verwiesen werden. Zu beachten ist auch hier die Aussage von Swissmedic, wonach derzeit ein Arzneimittelkompendium besteht, welches die gesetzlichen Anforderungen "erfüllt bzw. übertrifft" (Swissmedic Journal 1/2004, S. 24). Es ist nicht ersichtlich, inwiefern eine Konkurrenzierung dieses Angebots im öffentlichen Interesse liegt. Wenn zur Rechtfertigung einer Monopolisierung die Gefahr einer Zersplitterung der Arzneimittelinformation in Betracht gezogen wird (vgl. oben Ziff. 40) müsste die gleiche Überlegung dazu führen, dass ein eigenes Angebot von Swissmedic eher schädlich ist – mindestens aber nicht aus Gründen des Gesundheitsschutzes geboten. *Besonders paradox erschiene, wenn der Markteintritt von Swissmedic selbst den Anlass zur nachfolgenden Monopolisierung setze würde.*

56. Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Interesse wird oft auch der *Grundsatz der Subsidiarität* angeführt (RHINOW/SCHMID/BIAGGINI, a.a.O., S. 373). Bezogen auf das Verhältnis von Staat und Wirtschaft besagt dieser Grundsatz, dass das Gemeinwesen dann auf eine eigene wirtschaftliche Betätigung verzichten soll, wenn die Marktprozesse ein zufrieden stellendes Resultat hervorbringen. Vorliegend bedeutet die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips, dass Swissmedic auf eine eigene unternehmerische Tätigkeit verzichtet, solange ein Arzneimittelkompendium besteht, welches die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

d) Grundsatz der Wettbewerbsneutralität

57. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist "der Staat aus wirtschaftsverfassungsrechtlichen Gründen zur Wettbewerbsneutralität verpflichtet und darf seine wirtschaftliche Eigenbetätigung nicht privilegieren" (Urteil 2P.283/1999 und 2A.514/1999 vom 13. Juni 2000, E. 5b/cc). Der Grundsatz der Wettbewerbsneutralität ist Teil des Grundsatzes der Wirtschaftsfreiheit i.S.v. Art. 94 Abs. 1 BV). Verboten sind namentlich Quersubventionierungen aus dem Bereich hoheitlicher Tätigkeit (UHLMANN, a.a.O., S. 217).
58. Unter dem Gesichtspunkt der Wettbewerbsneutralität zwischen staatlichem und privatem Tätigwerden scheint vorliegend problematisch, dass Swissmedic einen erheblichen faktischen Vorteil geniesst, wenn sie selbst die Veröffentlichung der Arzneimittelinformation anbietet. Wenn eine Zulassungsinhaberin vor der Wahl steht, ein privates Unternehmen oder die amtliche Zulassungsstelle zu beauftragen, wird sie sich schon aus Bequemlichkeit auf die amtliche Stelle einlassen. Abgesehen davon ist klar, dass die Zulassungsbehörde sozusagen quasi von Amtes wegen einen guten Ruf besitzt. Bereits diese faktischen Wettbewerbsvorteile lassen daran zweifeln, dass ein echter Wettbewerb zwischen Swissmedic und privaten Anbietern möglich ist. Besonders problematisch erschiene überdies, wenn Swissmedic im gleichen Markt regulierend und unternehmerisch auftreten würde.

Es besteht offenkundig die Gefahr, dass die unternehmerische Tätigkeit von Swissmedic das private Angebot mittelfristig eliminiert. Teilweise wird gefordert, dass ein solches sog. "virtuelles Monopol" den gleichen Regeln untersteht wie eine rechtliche Monopolisierung (vgl. UHLMANN, S. 177 m.w.H.; offen gelassen durch das BGer. im Entscheid vom 23. September 2004, Urteil 2P.67/2004, E. 1.8). *Der Grundsatz der Wettbewerbsneutralität bestimmt somit vorliegend nicht nur die Modalitäten unternehmerischer Tätigkeit von Swissmedic (Frage*

des "Wie"), sondern weckt auch in grundsätzlicher Hinsicht Bedenken (Frage des "Ob").

e) Vergabe eines öffentlichen Auftrages

59. Auch im Bereich unternehmerischer Tätigkeit von Swissmedic in Konkurrenz zu einem privaten Angebot dürfte eine Ausschreibung zu Gunsten privater Dritter kaum etwas zur Rechtfertigung beitragen. Eine wirtschaftliche Tätigkeit, welche von privaten Dritten im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung ausgeübt wird, ist weiterhin dem Gemeinwesen zuzurechnen. Auftragnehmer und Besteller dieser Tätigkeit bleibt Swissmedic und damit die öffentliche Hand.
60. Für eine mögliche Randnutzung von Verwaltungsvermögen durch Swissmedic erschiene eine Ausschreibung möglicherweise sogar widersprüchlich, wenn Swissmedic einerseits Synergien nutzen will, für die eigentliche Nutzung aber Dritte beizieht. Zumindest erschiene es als ungewöhnlich, die Randnutzung von Verwaltungsvermögen durch Dritte bewirtschaften zu lassen.

IV. VERTRAUENSSCHUTZ

61. Zu prüfen ist vorliegend auch, ob die wirtschaftliche Tätigkeit von Documed konzessioniert wurde und somit die Veröffentlichung des Arzneimittelkompendiums durch Swissmedic (Monopol- oder Wettbewerbssituation) in Konzessionsrechte oder zumindest in eine geschützte Vertrauensposition von Documed eingreift.

Das Vorliegen einer eigentlichen Konzessionierung wurde vorliegend jedoch verneint. Documed (wie auch jede potenzielle Konkurrentin) bedarf nicht einmal einer staatlichen Erlaubnis für ihr Tätigwerden (vgl. oben, Ziff. 11). Dieser Einschätzung entsprechen die Schreiben von Swissmedic vom 9. Oktober 2003 und vom 23. November 2004, worin lediglich bestätigt wird, dass Documed die gesetzlichen Erfordernisse erfüllt. Es ist deshalb zu bezweifeln, dass eine Herausgabe des Arzneimittelkompendiums in eine geschützte Rechtsstellung i.S.v. Art. 9 BV eingreift.

62. Der Grundsatz des Vertrauensschutzes vermag vorliegend allerdings den Erlass einer angemessenen Übergangsordnung zu indizieren. In einem unveröffentlichten Entscheid vom 14. Juli 1997 (Urteil 2A.496/1996) hat das Bundesgericht festgehalten, dass das Vertrauen der Fleischimporteure auf ihre bisherigen Kon-

tingentszuteilungen zwar nicht der Einführung einer neuen Marktstruktur entgegenstehe, dass aber im "Im Rahmen einer Übergangsordnung den Interessen der bisherigen Importberechtigten Rechnung zu tragen" sei (BGer., a.a.O., S. 14 f.).

Mit Blick auf die 25-jährige Tätigkeit der Documed und die Tatsache, dass Documed derzeit rund 25-30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, erscheint die *Forderung nach einer angemessenen Übergangslösung* angemessen (sofern überhaupt eine Tätigkeit von Swissmedic im Bereich des Arzneimittelkompendiums in Frage kommt). Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine unternehmerische Tätigkeit von Swissmedic im Bereich des Arzneimittelkompendiums zumindest aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen nicht ohne weiteres absehbar gewesen ist.

V. ZIVILRECHT

63. Nicht näher vertieft wird vorliegend die Frage, ob und welche Urheber- und Verwendungsrechte Documed am vorliegenden Arzneimittelkompendium hat, ob einem entsprechenden Sprach-, Sammelwerk oder Computerprogramm mit Blick auf Art. 5 Abs. 1 lit. c URG (Entscheidungen, Protokolle und Berichte von Behörden und öffentlichen Verwaltungen) Schutzfähigkeit zukommt und ob ein Konkurrent das marktreife Arbeitsergebnis von Documed behündigt hat (Art. 5 lit. c UWG). Die entsprechenden Fragen sind Gegenstand einer privatrechtlichen Klage von Documed vor dem Zivilgericht Basel-Stadt. Klar ist, dass eine unternehmerische Tätigkeit von Swissmedic im Monopol- oder Wettbewerbsbereich allfällig bestehende Urheberrechte von Documed nicht verletzen dürfte.

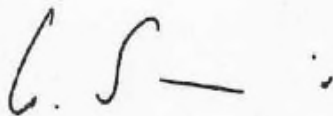
VI. BEANTWORTUNG DER GUTACHTENSFRAGEN

64. Aufgrund der vorstehenden Ausführungen sind die eingangs gestellten Gutachtensfragen wie folgt zu beantworten:
1. Die Veröffentlichung der Arzneimittelinformation durch Swissmedic unter Ausschluss aller übrigen Anbieter erscheint unzulässig. Für eine solche Monopolisierung einer privatwirtschaftlichen Tätigkeit sind weder eine genügende gesetzliche Grundlage noch ein hinreichendes öffentliches Interesse

vorhanden. Eine nachfolgende Vergabe an private Dritte trägt nichts zur Rechtfertigung der Monopolisierung bei.

2. Eine konkurrenzierende Tätigkeit von Swissmedic im Bereich des Arzneimittelkompendiums ist als unternehmerische Betätigung des Staates zu erachten. Es fehlt an einer genügenden gesetzlichen Grundlage und an einem hinreichenden öffentlichen Interesse. Eine Ausschreibung ändert wenig an dieser Beurteilung. Möglich ist allenfalls eine untergeordnete unternehmerische Tätigkeit von Swissmedic im Rahmen von Art. 69 Abs. 2 HMG (Randnutzung von Verwaltungsvermögen).

Basel, 7. April 2005



Prof. Dr. Gerhard Schmid



Dr. Felix Uhlmann